

1505270-57.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a atitude ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505270-57.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505270-57.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em
Flagrante - 2058467/2022 - 13º Distrito Policial - Casa Verde, AM7667/2022 - 13º
Distrito Policial - Casa Verde, 2058467 - 40º D.P. VILA STA MARIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE EDUARDO GARCIA OSORIO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo nº 361.22

VISTOS.

JOSE EDUARDO GARCIA OSORIO, colombiano, qualificado à fl. 04, foi denunciado por infração ao disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque consta, que no dia 03 de março de 2.022, por volta de 00h01, à Avenida Otaviano Alves de Lima, 2.600, Limão, São Paulo, transportava, para consumo de terceiros, cerca de 1.003,3g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida à fl. 67.

Foi apresentada defesa preliminar à fl. 98.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e o réu foi interrogado.

Em debates, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade do crime.

A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu pela ausência de provas suficientes para condenação. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da minorante, a pena no mínimo, regime mais brando e direito de recurso em liberdade. É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13, dando conta do tijolo de cocaína, além dos R\$ 337,85 encontrados e apreendidos em poder do réu.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 122/124, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para cocaína.

A autoria também é incontestada.

De fato, os argumentos de sua defesa técnica não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e as provas diretas contra ele derivadas, em especial, pelas testemunhas inquiridas e declarações do próprio increpado que nada de exculpatório trouxe aos autos.

Na Delegacia de Polícia o réu declarou que tem nacionalidade colombiana, porém entende e se expressa na língua portuguesa; não soube esclarecer quanto a procedência do entorpecente, somente alegando que estava em um posto de gasolina quando um indivíduo lhe ofereceu R\$ 500,00 (quinhentos reais) para dirigir um carro até certo ponto, o qual não soube indicar, quando foi abordado por policiais militares, fls. 04.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o réu forneceu sua versão dizendo que esse dia eu estava andando pelo posto, porque cheguei apenas há dezesseis dias antes no Brasil. Uma pessoa perguntou se eu sabia dirigir carro, eu disse que sim, então ele me pediu para fazer o favor de levar o carro para outro posto, pelo valor de 500 reais. Ele não sabia que tinha limite de velocidade, quando a polícia veio atrás dele, com sinais sonoros. Então parei em um posto, por segurança. Eu fui abordado, eu estava nervoso porque nunca tinha passado por isso. Eles revistaram o carro e encontraram, debaixo do banco do passageiro, um pacote e perguntaram o que era isso. Eu disse que era cocaína e que não era meu, e sim da pessoa que havia me contratado. Eu não sabia que havia droga no carro e não desconfiei de nada porque estava há pouco tempo aqui no Brasil e não sabia se 500 reais era muito ou pouco dinheiro. Não conhecia os policiais anteriormente. Eu já tinha vindo antes ao Brasil, morava em Manaus, onde pescava e vendia. Não era habilitado para conduzir veículos automotores no Brasil.

Ocorre porém, que os argumentos do acusado não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual, não convenceu. O réu não apresentou qualquer versão plausível para sua prisão. Limitou-se a dizer o que todos dizem quando são surpreendidos quando são detidos transportando grande quantidade de drogas, ou seja, que foi contratado apenas para conduzir um veículo, mas não sabia que continha drogas.

No entanto, as justificativas do acusado mostram-se no mínimo pueris. Ora se morava em Manaus, vendendo peixes, sabia muito bem o valor do dinheiro Nacional, de maneira que sua fala no sentido de que não desconfiou de que transportava drogas não encontra respaldo no contexto probatório.

Não há como se acreditar que os policiais resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusar o réu da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-lo condenado. Tanto que o próprio réu, em seu interrogatório, afirmou que não conhecia os policiais. Mesmo porque, não se pode crer que o réu estivesse com tamanha quantidade de drogas em seu poder, não fosse para o exercício da traficância.

Desta forma, não se tem nos autos, um indício sequer que pudesse evidenciar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida com a finalidade única de prejudicar o réu ou mesmo acusá-lo falsamente. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso.

É certo que a quantidade da droga por si só, não é suficiente a caracterizar o crime de tráfico. No entanto, o montante e variedade de drogas apreendidas em poder do réu, não deixam dúvidas que serviam para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, a atitude suspeita do réu ao avistar os policiais, a enorme quantidade de cocaína que transportava, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

Tanto é assim que os policiais militares responsáveis pela prisão do réu, Nelson Joaquim da Silva Junior e Lucas Rodrigues Oliveira, ouvidos em Juízo, relataram em uma só voz, de forma firme e segura que estávamos em patrulhamento pela Marginal Tiete, quando o veículo passou por nós muito rápido. Achamos estranho e optamos pela abordagem. O réu conduzia o veículo e disse que era Colombiano. Ele apresentou o passaporte, indagado a quanto tempo estava no Brasil, para onde estava indo e de onde vinha, quando ele disse que não sabia. Feita a vistoria no veículo, embaixo do banco do passageiro, havia uma sacola, no interior da qual havia um tijolo de cocaína. Indagado, o réu confirmou que se tratava de cocaína. Indagado para onde estava levando, ele disse que não sabia, que tinha pego o carro em um posto de gasolina e que ia para o fim da Avenida. Ele disse que ia receber 500 reais para transportar a droga. Reconheceram o réu e não o conheciam anteriormente.

Os policiais narraram com segurança e precisão como se deu a prisão do acusado, relatando todos os detalhes, desde o patrulhamento de rotina em via pública, a atitude suspeita ao visualizar os policiais e arriscar uma ultrapassagem em alta velocidade, sua abordagem, o encontro das drogas no banco passageiro do carro, bem como dinheiro em seu poder, sua confissão informal, até final prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Em que pesem, pois, os argumentos da defesa, alegando em síntese que tudo não passou de uma armação para incriminar o réu e que os policiais não lograram êxito na prova da traficância, vejo nos autos que todas as circunstâncias apontam em sentido contrário. Neste contexto, em vista da grande quantidade de drogas encontradas em poder do réu, e ainda o relato seguro e firme por parte dos policiais, resta

inexoravelmente comprovado que mantinha substância tóxica para consumo e entrega a terceiros.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercância, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo pois, impossível a absolvição. Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter o agente, sido surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Em arremate, o fato do réu ter sido usado como os conhecidos "mulas do tráfico" em nada abala a tipificação constante na denúncia. Os chamados traficantes vapor, ou mulas, devem ser penalizados, com o mesmo rigor, uma vez que integram a cadeia do tráfico de forma fundamental, pois com o objetivo de conseguirem lucro fácil, assumem todos e quaisquer riscos a fim de aliciarem novos clientes e usuários. Destarte, não evidenciou-se qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, atento dolo normal à espécie. O acusado é primário e sem antecedentes criminais, de maneira que fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado primário, sem qualquer antecedentes, e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa. Assim, considerando-se a capacidade lesiva das drogas em questão, tratando-se de grande quantidade de cocaína, reduzo a pena base em 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Sobre o tema, já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que " O art. 42 da Lei nº 11.343/06 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da nova lei de Tóxicos. Na hipótese, à luz do art. 42 da lei 11.343/2006, a natureza da substância entorpecente apreendida - 13 (treze) pedras de crack - justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja: 2/3" (5ª T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Dje 05/06/2012). O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar JOSE EDUARDO GARCIA OSORIO, como incurso nas penas do artigo 33, §4º da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente semiaberto a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

O condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, pois, o tráfico ilícito de entorpecentes é crime tido como hediondo, daqueles cuja gravidade não permite o início do cumprimento da pena em regime aberto.

Nem mesmo a atual decisão do STJ é capaz de ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que a quantidade, drogas apreendidas em poder do réu, somada a sua reincidência específica, não autorizam o reconhecimento de regime mais brando.

Tanto é assim que analisando temas semelhantes, o STF já firmou entendimento no sentido de ser plenamente possível o reconhecimento da minorante prevista na Lei de Drogas, em conjunto com o cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, sem que

haja qualquer vinculação ou obrigatoriedade de ser reconhecido o regime aberto. Há que se consignar que cada caso concreto possuem fatos diferentes, que afastam a obrigatoriedade e a rigidez imposta pelo STJ, de maneira que a aplicação e o reconhecimento da minorante, bem como o regime inicial da pena devem ser analisados de acordo com cada situação específica imposta e apresentada em cada processo. No sentido vale trazer a colação o seguinte julgado: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO ESCOLHIDA. REPRIMENDA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. NOCIVIDADE DA DROGA QUE APONTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. Razão não assiste ao agravante. Consoante consignado na decisão agravada, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 413.085/SC, não reflete flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, já que alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vide: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 3 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO ESCOLHIDA. REPRIMENDA MANTIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. NOCIVIDADE DA DROGA QUE APONTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. Esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Deve ser mantida a fração redutora de 1/3, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão recorrido aponta a necessidade de uma maior repressão do delito, ante a sua gravidade concreta, evidenciada esta última pela quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (crack). Ademais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem implica, sem dúvida, revolver o acervo fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - No caso, inexiste coação ilegal a ser sanada, pois, embora o paciente seja primário e a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão comporte, em princípio, o regime inicial aberto, o regime intermediário foi fixado com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada nocividade da droga apreendida (crack), elemento que, inclusive, justificou a escolha da fração redutora de 1/3 pelo tráfico privilegiado. Inteligência dos art. 33, § 3º, do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - No que tange à possibilidade de substituição da pena - Esta Corte vem decidindo que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração

reduzidora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Deve ser mantida a fração redutora de 1/3, pelo reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando o acórdão recorrido aponta a necessidade de uma maior repressão do delito, ante a sua gravidade concreta, evidenciada esta última pela quantidade e nocividade do entorpecente apreendido (crack). Ademais, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem implica, sem dúvida, revolver o acervo fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. - Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Inteligência das Súmulas n. 440/STJ e 718 e 719 do STF. - No caso, inexistente coação ilegal a ser sanada, pois, embora o paciente seja primário e a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão comporte, em princípio, o regime inicial aberto, o regime intermediário foi fixado com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada nocividade da droga apreendida (crack), elemento que, inclusive, justificou a escolha da fração redutora de 1/3 pelo tráfico privilegiado. Inteligência dos art. 33, § 3º, do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. O Supremo Tribunal Federal passou a admitir tal possibilidade, nos termos do art. 44 do Código Penal, reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, por meio da Resolução n. 5/2012. - Na espécie, embora adimplido o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP, a nocividade do entorpecente apreendido (crack) não recomenda a substituição, nos termos do inciso III do art. 44 do CP. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido" (fls. 428/429 e-STJ).

De outra banda, o regime semiaberto se justifica, porque a despeito de se tratar de crime de tráfico, assemelhado aos crimes hediondos, não há indícios de que trata-se de grande traficantes.

Não é possível, contudo a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovente deve ser segregado do convívio social.

Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apelo. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram. No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (inciderent tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos, pode ser aplicada e reconhecida. Além disso, não se encontram presentes os requisitos

necessários à concessão de qualquer benefício, uma vez que o crime em apreço possui natureza gravíssima, cujas circunstâncias caracterizadas pelo lucro fácil em detrimento da saúde das pessoas de nossa sociedade, e as consequências do delito que levam à desestabilização familiar e social, indicam que a substituição não se mostra suficiente como forma de retribuição estatal.

De forma idêntica, a Resolução nº 05/12, do Senado Federal, também não obsta aquele posicionamento, visto que o artigo 44, "caput", da Lei de Tóxicos permanece íntegro. Trata-se ainda de crime equiparado aos crimes hediondos, não tendo assim, referida Resolução retirado o caráter hediondo do crime, circunstância que levou o legislador constituinte a prever um tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas. Em arremate, o condenado respondeu a todo o processo preso, e assim devem permanecer, ainda mais agora, diante de uma sentença penal condenatória em primeiro grau, tratando-se de condenação de extrema gravidade, de crime dos quais não se admite liberdade provisória, ex vi do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06, estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, qualquer outra pena, que não a privativa de liberdade, em regime semiaberto, sem direito de recurso em liberdade, mostrar-se-ia por demais tênues, como medida de repressão, retribuição e ressocialização para o caso em apreço. A sociedade está aterrorizada com a crescente criminalidade e proliferação do tráfico de drogas, que vem assolando e liquidando nossa juventude.

Assim, em atenção aos motivos e circunstâncias supras, não concedo ao condenado o direito de aguardar o trânsito em julgado desta em liberdade.

Deixo, por fim, de aplicar os efeitos imediatos da detração, porque o condenado não se encontra preso tempo suficiente para obter os benefícios da progressão de pena.

Além disso, não se tem notícias, neste Juízo de Conhecimento, acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao reconhecimento do benefício, vale dizer, não consta nos autos, atestado de conduta carcerária, imprescindível à concessão da progressão.

Recomendem-se a remoção do condenado para estabelecimento adequado ao regime semiaberto.

Com o trânsito em julgado desta oficie-se para incineração dos entorpecentes, com a perda do dinheiro apreendido em favor da União.

Após o trânsito em julgado, tratando-se de réu estrangeiro, oficie-se ao Ministério da Justiça, a fim de serem tomadas as medidas cabíveis.

Custas na forma da Lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA